

1500421-17.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... que se destinavam, sim, ao tráfico, tanto que já possuía dinheiro proveniente do tráfico em sua posse. Ou seja, as circunstâncias do fato, aliados às máximas de experiências, indicam de forma concludente que as drogas eram destinadas, sim, a ulterior entrega ao consumo de terceiros, deitando por terra a negativa de autoria de parte dos acusados, que restaram isoladas no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1500421-17.2021.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO CARDENAS BOEMI e outro

Data da Audiência:

12/01/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive do réu), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, do Defensor, o advogado Vinicius Adriano Cassamasimo Ramos, OAB 356869/SP, e dos Acusados Rodrigo Cardenas Boemi e Jonathan Donizete de Almeida Medeiros. Na "sala virtual" permaneceram exclusivamente o Defensor e seu representado para contato prévio. Antes de serem inquiridas as testemunhas foram devidamente advertidas acerca da incomunicabilidade. Foram ouvidas as testemunhas Fabio Bosco e Antonio César Alapone de Oliveira arroladas pelas partes e as testemunhas Carolina Aparecida de Almeida, Adriana Xavier Correa, Cleide Ferreira de Lima Santos, Tatiane Cristina Santiago Pereira de Oliveira e Marcos Adriano Gonçalves arroladas pela defesa. A Defesa desistiu da oitiva da testemunha Sandra Aparecida Santana, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Em seguida os réus foram interrogados. Os depoimentos foram registrados pelo sistema Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM^(a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, acham-se processados os acusados como incursos no artigo 33 da Lei de Tóxicos, na forma do artigo 29 do Código Penal, em face dos fatos detalhadamente narrados na denúncia. Concluída a instrução, a ação penal merece proceder. A materialidade delitativa encontra respaldo nos laudos de exames químico-toxicológico acostados aos autos. Autoria e existência delitativa, ao seu turno, vêm comprovadas nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório. Ouvidos nos autos, tanto em juízo como em solo judicial, os policiais militares narraram toda dinâmica da

apreensão das drogas e prisão dos acusados. Afirmaram que realizavam patrulhamento de rotina quando puderam observar os acusados, que ao notarem a aproximação policial, arremessaram algum objeto. Realizaram a abordagem e com eles apreenderam celular e dinheiro, e constatado que o que havia sido arremessado era uma porção de crack e três pinos de cocaína. Dando continuidade à diligência, junto a um pé de mamona contíguo a onde os acusados foram detidos, localizaram e apreenderam uma sacola contendo mais de uma centena de porções de cocaína já prontas e embaladas para comercialização, bem como de crack e uma porção média de cada um dos entorpecentes, tudo em similaridade ao que portavam os agentes e haviam dispensado quando da aproximação da viatura. As palavras dos milicianos revestem-se de imensurável valor probatório, uma vez que isentas e desprovidas de qualquer intenção de prejudicar o agente. Demais disso, não há nenhum elemento capaz de indicar uma suposta suspeição do agente público; ao contrário, revela de forma absolutamente convincente toda dinâmica da diligência que resultou na prisão em flagrante. Dessa forma, patente a conduta atribuída ao réu, sendo certo que a quantidade da droga, dividida em porções e acondicionada em unidades embaladas e prontas para a mercancia clandestina, indica claramente que se destinavam, sim, ao tráfico, tanto que já possuía dinheiro proveniente do tráfico em sua posse. Ou seja, as circunstâncias do fato, aliados às máximas de experiências, indicam de forma concludente que as drogas eram destinadas, sim, a ulterior entrega ao consumo de terceiros, deitando por terra a negativa de autoria de parte dos acusados, que restaram isoladas no cenário dos autos. Vale anotar que as testemunhas de defesa ouvidas nada trouxeram de relevante acerca dos fatos, relatando um cenário no sentido de que a prisão teria ocorrido em ponto diverso daquele em que realmente se sucedeu a ação policial. Entretanto, as versões são confusas, desprovidas de credibilidade e, sobretudo, de uma segurança acerca dos fatos em si, em especial do momento da apreensão dos entorpecentes e prisão dos acusados. Vale reforçar que as versões que apresentaram não se coadunam sequer com palavras deduzidas pelos réus em seus interrogatórios, que se limitaram a narrar a abordagem e prisão, negando a propriedade dos entorpecentes. Portanto, demonstradas autoria e materialidade, pugna a Justiça Pública pela procedência da ação penal, condenando-se os acusados nos termos da denúncia. Não se apresenta cabível a aplicação do redutor, haja vista os maus antecedentes e comprovada reincidência dos acusados, além do que há que se fixar pena base acima do mínimo legal, dada a elevada potencialidade lesiva da conduta a eles atribuída, pois que em concurso tinham elevada quantidade de entorpecentes, atingindo número considerável de usuários. Na mesma esteira, a se considerar a natureza equiparada a hedionda do crime, bem como os antecedentes e reincidência específica de ambos, deve ser fixado regime fechado para início de cumprimento da sanção carcerária. Dada a palavra à Defensoria Pública, foi dito: MM. Juiz: Segundo consta na denúncia, o dia 22 de março de 2021, nesta cidade e comarca, o réu mantinha em depósito drogas que supostamente seriam destinadas ao tráfico. Em razão disso foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O acusado foi notificado e apresentou sua defesa preliminar. A audiência de instrução, debates e julgamento foi realizada em 12 de janeiro de 2022, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia e o réu foi interrogado. PROVA ORA COLHIDA: As testemunhas PM Fábio Bosco e PM Antonio César Alapone narraram que estavam em patrulhamento viram os réus saindo de uma construção. Os réus foram abordados na esquina da rua e as drogas foram localizadas posteriormente. Houve a necessidade de chamar o canil da polícia militar para varredura no local. Informa que os réus foram abordados em local muito próximo ao terreno com início de construção onde foram localizadas as drogas. A informante Carolina Aparecida de Almeida narrou que estava presente no dia dos fatos. Estava na sua casa, localizada na rua Lauro Batista dos Santos. Jonathan estava com uma pessoa, que depois descobriu se tratar de Rodrigo, estavam descendo na rua da sua casa, numeral 18, e presenciou os policiais revistando os dois e nada foi encontrado. Foram abordados descendo a rua. Depois de cerca de dez minutos, descenderam todos para a esquina da rua Osvaldo Thibes e já estavam detidos na viatura. Acompanhou a todo momento a ocorrência. Os policiais entraram dentro de um terreno e permaneceram cerca de 20 a 25 minutos e, então, saíram com uma sacola.

Informa que o local onde foram abordados e o terreno onde foram localizadas as drogas não era próximo, dava cerca de cem metros. A testemunha Adriana Xavier Correa, por sua vez, narrou que não presenciou os fatos e não conhece os réus. A testemunha Cleide Ferreira de Lima Santos, por sua vez, afirmou que estava em um bar localizado na Vila Padrão. Viu o Jonathan e o "outro" menino estava no bar. Viu que conversaram e combinaram de ir buscar o filho de Jonathan. Viu a viatura abordando os réus na Rua Lauro Batista, entrou em casa e ao sair viu outra viatura chegando. Colocaram os meninos dentro da viatura e levaram para outra rua. Não passaram pela rua Oswaldo Thibes, foram para a Rua Lauro Batista onde mora o filho de Jonathan. As ruas são distantes, há muitas casas na rua. Não acompanhou o resto da abordagem na Rua Oswaldo Thibes. A testemunha Tatiane Cristina Santiago Pereira de Oliveira narrou que estava chegando na sua casa e viu uma viatura subindo a rua Lauro Batista. Abordou os moços e um dos policiais desceu na Rua Oswaldo Thibes em um terreno e retornou com uma sacola. Afirmou que há cerca de seis casas que separam o local de abordagem e o início da rua onde havia o terreno em que os policiais localizaram as drogas. A testemunha Marcos narrou que viu os dois descendo a Rua Lauro Batista Santos quase em frente à casa da mãe do filho de Jonathan e viu que eles foram abordados. Tirou fotos do que aconteceu. A abordagem aconteceu na frente da casa do depoente e presenciou a revista e nada foi localizado. Afirmo que o local da abordagem e o local onde foram levados fica cerca de 200 metros. Afirmou que a viatura veio em sentido contrário ao caminho que os réus faziam, isto é, os réus desciam a rua Lauro Batista e a viatura subiu a rua e foi de encontro aos réus. Ao ser interrogado, Rodrigo narrou que a acusação não é verdadeira. Narrou que saiu do sistema penitenciário em 11 de março. Informou que no dia que encontrou Jonathan estava comendo em uma lanchonete. Foi com Jonathan conversando até a casa de Carolina, para buscar o filho de Jonathan. Quando chegaram, veio uma viatura em sentido contrário, fez a abordagem. Tinha um celular e dez reais. Ficaram na abordagem, sentado no chão. Um dos policiais desceu a rua e ao retornar o policial pediu para os réus serem algemados. Foram para delegacia e na delegacia foi apresentado drogas imputadas a ele. É o relatório. FUNDAMENTOS JURÍDICOS: A ação penal deve ser julgada improcedente. A versão apresentada pelas testemunhas acusatórias não é suficiente para demonstrar além de qualquer dúvida razoável que o Acusado estivesse envolvido na prática do crime de tráfico de drogas. Primeiramente, veja-se que não há indícios suficientes de que o acusado estava praticando o crime de tráfico de drogas, sendo certo que sua versão não foi infirmada pelo restante da prova coligida. Verifica-se, nesse ponto, que o Acusado, desde a fase policial, nega peremptoriamente ser o proprietário da droga localizada, mantendo a mesma versão desde a fase policial (fls. Fls. 5-6). Por outro lado, as testemunhas acusatórias narram que a droga não foi apreendida com o réu, mas sim dentro de uma

construção abandonada. Além disso, é preciso ponderar que o Acusado não teria sido avistado em atividade típica de traficância, já que inexistiu a identificação de possíveis usuários. Ainda, segundo os próprios policiais, não houve campana, de modo que inexistiu qualquer observação prévia que pudesse concretizar a alegação de que o acusado estava atuando na venda de entorpecentes. Mas não é só. A partir de investigação defensiva realizada pelo advogado do corréu Jonathan, extrai-se fotos (fls. 101/103) e depoimentos de testemunhas dos fatos que contraditam a versão policial (mídia audiência virtual). Com efeito, restou demonstrado durante o curso processual, inclusive com registro de imagens, que os réus foram abordados na rua Lauro Batista Santos, na altura do numeral 18. Já as drogas, foram localizadas em terreno localizado na Rua Oswaldo Thibes, em local distante da onde estavam. De outro lado, três populares afirmaram que viram o momento em que os réus foram abordados e que não presenciaram a localização de entorpecentes durante a revista pessoal. Afimam, ainda, que as drogas foram localizadas em um terreno vago, em outra rua, distante do local onde foram encontradas as substâncias ilícitas. Outrossim, a versão dos acusados é uníssona e integralmente corroborada pelas testemunhas de defesa que foram ouvidas no curso processual. Ante ao exposto, entende-se que o cotejo da prova no caso concreto não satisfaz o standard probatório apto à condenação do Acusado, razão pela qual se requer a improcedência

da ação penal, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

DOSIMETRIA DA PENA: Subsidiariamente, na hipótese de condenação, em respeito ao princípio da eventualidade, passa-se à análise da dosimetria da pena a ser imposta ao acusado. Na primeira fase, pleiteia-se a fixação da pena-base no mínimo legal, ante a ausência de requisitos capazes de exasperá-la, nos termos do art. 59 do Código Penal. Muito embora o artigo 42 da Lei de Drogas estabeleça como critério para a dosagem da pena a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, é impossível a aplicação de tal norma, na medida em que é difícil avaliar qual quantidade e quais variedades de drogas seriam suficientes para justificar a aplicação da causa de diminuição abaixo do máximo estabelecido em lei. Assim, a inexistência de tal parâmetro faz com que a aplicação de pena seja feita de maneira completamente arbitrária. Na segunda fase, eventual exasperação da pena em razão da reincidência, deve ser limitada à fração de 1/6. A agravante de calamidade pública descrita na denúncia deve ser afastada, uma vez que é indispensável a prova do nexo entre a situação vivenciada no período de calamidade e o crime cometido, sob pena de se caracterizar responsabilidade penal objetiva, refutada por nosso ordenamento jurídico. Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição da pena.

DETRAÇÃO DA PENA: Requer-se a detração da pena haja vista que o réu está preso desde os fatos (22 de março de 2021), o que, nos termos do atual entendimento do STJ (AgRg nos EDcl no AREsp 1674599/SP) deve ensejar a detração do período de custódia cautelar, ainda que não implique em alteração do regime inicial.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO: Quanto é ilegal a fixação do regime fechado, apenas pelo fato do réu ser reincidente. Nesse sentido, confira-se o entendimento sumulado do STF: "A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir, exige motivação idônea". Nessa toada, requer-se a fixação do regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, "b" e "c", do Código Penal. Requer, por fim, a concessão de gratuidade judiciária ao Acusado, isentando-os do pagamento de custas processuais. Diante do exposto, requer sejam acolhidas as teses defensivas, nos termos da fundamentação supra. Por fim, requer seja concedido o direito de recorrer em liberdade, bem como a gratuidade de justiça, com isenção de custas processuais, por se tratar de pessoa hipossuficiente nos termos da lei. Dada a palavra ao Dr. Defensor, este se manifestou através do sistema audiovisual. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. RODRIGO CARDENAS BOEMI e JONATHAN DONIZETE DE ALMEIDA MEDEIROS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 22 de março de 2021, por volta das 16 h e 15 min, na Rua Evaldo Tibes, n. 10, Vila Prado, nesta Cidade e Comarca de Itapetininga, previamente ajustados e com unidade de desígnios, guardavam e mantinham em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, cinquenta e oito pedras de "crack", com peso de 16,52 gramas; setenta e um microtubos contendo "cocaína"; uma porção a granel de "cocaína", embalada com plástico amarelo; e uma porção a granel de "cocaína", embalada com plástico branco, todas com o peso de 33,96 gramas. Os Réus foram notificados, fls. 250 - Rodrigo Cardenas e fls. 252 - Jonathan Donizete. O Dr. Defensor apresentou pedido de liberdade provisória, fls. 268/271, o MP manifestou-se, fls. 275, e o pedido foi indeferido, reiterando-se a decisão de (fls. 260/261), fls. 276. O Acusado Jonathan Donizete apresentou defesa preliminar, fls. 291/292. Em 24 de setembro de 2021 foi proferida decisão por meio da qual os Réus foram mantidos em prisão preventiva, fls. 304/305. O Réu Rodrigo Cardenas apresentou defesa preliminar, fls. 315/316. A denúncia foi recebida, fls. 317/318, e, em seguida, os Réus foram citados, fls. 358 - Jonathan Donizete e fls. 360 - Rodrigo Cardenas. Durante a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, e, ao final, os Réus foram interrogados (gravação por videoconferência). Alegações finais apresentadas pelas partes, o MP pugnou a condenação e as Defesas, as absolvições. É o relatório. DECIDO. A ação é procedente. A materialidade acha-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência, fls. 12/14, Auto de Exibição e Apreensão, fls. 15/16, no Laudo de constatação, fls. 20/23, bem como no Exame químico-toxicológico n. 93809/2021, fls. 193/196, constatando-se a presença do princípio ativo cocaína. Fábio Bosco e Antônio César Alapone de Oliveira, policiais militares, disseram que

estavam em patrulhamento quando viram os réus saírem de uma construção, e eles, ao verem a viatura, tiveram um comportamento estranho e dispensaram algo; feita a abordagem, com Rodrigo os policiais localizaram R\$ 10,00 e um celular e, com Jonathan, um celular. Vistoriaram o local onde algo tinha sido jogado e encontraram três pinos de "cocaína" e um invólucro de "crack"; prosseguiram em vistoria na construção e encontraram as demais drogas. Os réus negaram a posse dos entorpecentes. Foi acionado o canil. Carolina Aparecida de Almeida, Testemunha, disse que estava em frente à casa quando viu o Réu Jonathan descer a rua com outra pessoa; na sequência foram abordados pelos policiais, porém nada de ilícito foi encontrado, então os policiais foram até um terreno localizado em outra rua, de onde voltaram com um pacote e depois conduziram os réus até à Delegacia de Polícia. Adriana Xavier Correa, Testemunha, disse que não conhece os acusados e nada presenciou. Cleide Ferreira de Lima Santos, Testemunha, disse que estava em um bar, quando passou o Jonathan e conversou com o outro Réu, que saíram juntos; na rua ambos foram abordados, mas nada foi encontrado; depois o policial foi até um terreno e conduziu os acusados. Tatiane Cristina Santiago Pereira de Oliveira, Testemunha, disse que estava na rua quando viu os réus descerem, ambos logo foram abordados pelos policiais, que nada encontraram com os acusados, mas depois foram até um terreno e na sequência fizeram a condução de todos à Delegacia de Polícia. Marcos Adriano Gonçalves, Testemunha, disse que viu a abordagem e tirou fotos, sabe que um policial foi até um terreno que se localizava longe do ponto da ação policial. Rodrigo Cardenas Boemi, Réu, ao ser interrogado, disse que encontrou o Réu Jonathan e ambos passaram a caminhar juntos, mas foram abordados em rua, depois foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde lhe disseram que seriam presos pelas drogas que não lhe pertenciam. Jonathan Donizete de Almeida Medeiros, Réu, ao ser interrogado, disse que se deslocava à casa do filho para visita-lo, quando encontrou o Correu, e, em certo momento, foram abordados pelos policiais. As drogas não lhe pertenciam. Confrontando-se a prova coligida, é inconteste que os réus eram os proprietários de parte das drogas, as que foram dispensadas, pois as testemunhas os viram dispensá-las, mas não é possível aferir se os outros entorpecentes encontrados no local lhes pertenciam, pois não houve observações pretéritas para saber se os acusados lá tinham permanecido por muito tempo no atendimento de usuários e se se deslocavam periodicamente para colher os entorpecentes no ponto em que foram armazenadas as outras porções, para fornecimento a eventuais compradores. Não há qualquer outra prova além da circunstancial. Há dinheiro, que não pode ser visto como fruto do comércio clandestino, já que nenhuma prática comercial foi constatada. A ligação dos acusados com parte dos entorpecentes apreendidos não restou demonstrada, na medida em que é plausível que lá estivessem para comprar drogas de algum vendedor, o qual, ao ver a viatura, empreendeu fuga e abandonou as porções da substância ilícita. As testemunhas arroladas pela Defesa em nada contribuíram para a descoberta da verdade real, pois viram parte da ação, o instante em que houve a abordagem, que de fato não ocorreu no terreno, mas em outro local, pois os policiais viram ambos deixarem o terreno, onde, posteriormente, entorpecentes foram apreendidos. Em nenhum momento os policiais disseram que as drogas tinham sido encontradas com os acusados ou que estes estivessem no terreno quando da abordagem. Ademais, o fato de terem sido abordados em outra rua, se é que isso de fato ocorreu, em nada modifica o quadro probatório, e as fotos de fls. 101/103 em nada contribuem à elucidação dos fatos e não podem ser consideradas por não sabe a exata localização. Em síntese, em virtude de todas essas circunstâncias, não se autoriza a prolação de decreto condenatório por infração ao artigo 33 da Lei de Drogas e mister é a desclassificação da conduta imputada ao Réu para a tipificada no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06, o que faço com fulcro no artigo 383 do Código de Processo Penal. II – DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal). Fixada a responsabilidade dos acusados, passo à dosimetria da pena. ART. 28, DA LEI 11.343/2006: Atento às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e aos critérios contidos no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 aplico ao Réu a pena de advertência. III – DECIDO. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e o faço para DESCLASSIFICAR a imputação contida na denúncia e o faço para condenar RODRIGO CARDENAS BOEMI e JONATHAN DONIZETE DE ALMEIDA

MEDEIROS, qualificados nos autos, a pena de ADVERTÊNCIA, dando-o como incurso no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06. Dá-se a pena por cumprida. Sem condenação nas custas. Defiro a liberação do dinheiro e dos celulares apreendidos. Expeça-se alvará de soltura, com urgência. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 12 de janeiro de 2022. Eu, (Marina Alice Correa de Almeida), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA